

1502821-29.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... GUILHERME pela prática do delito de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente, e do delito de corrupção de menores, ambos em período de calamidade pública e em concurso formal.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da IMPROCEDÊNCIA da ação penal, nos seguintes termos:

I) QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

É inevitável a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502821-29.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502821-29.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Indiciado:

GUILHERME ALVES PAGAMONHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

GUILHERME ALVES PAGAMONHA (RG. 50849747/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006; e artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos combinados o artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal. Segundo consta da denúncia, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 17h00min, na Rua Charles Cingria, n.º 10, Jardim Quisisana, nesta cidade e Comarca de São Paulo, em situação de calamidade pública de saúde causada pela pandemia do Covid-19), GUILHERME ALVES PAGAMONHA, previamente ajustado e com unidade desígnios com o adolescente João Vitor do Carmo Santos Araújo (nascido em 06/06/2005), trazia consigo, para a entrega e consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) papelotes cocaína com peso líquido de 16,3g (dezesesseis gramas e três decigramas; 132 (cento e trinta e duas) porções de crack, com peso líquido de 57,2g (cinquenta e sete gramas e duas decigramas); e 121 porções de tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 235,02g (duzentas e trinta e cinco gramas e duas decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, hora e local acima descritas, GUILHERME ALVES PAGAMONHA facilitou a corrupção de João Vitor do Carmo Santos Araújo, com então 16 (dezesesseis) anos de idade, com ele praticando o delito

de tráfico de drogas.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritos acima, GUILHERME, aproveitando-se do menor tráfego de transeuntes e diminuto policiamento ocasionados pela pandemia do vírus Covid-19, trazia consigo os entorpecentes acima descritos, destinados à venda e distribuição a terceiros, custodiados no interior de uma mochila.

A autoria do presente crime somente foi descoberta, porque policiais militares, em patrulhamento pela Rua Charles Cingria, conhecido ponto de mercancia de entorpecentes, deliberaram por abordar o denunciado e o adolescente infrator, na altura do numeral 10, ao constatarem que eles conversavam em uma praça na posse de uma mochila.

Em revista na mochila que o denunciado trazia consigo, foram apreendidos os entorpecentes acima descritos. Já em revista pessoal, foi apreendida a quantia de R\$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos), em notas de pequeno valor. Em poder do adolescente foi apreendida uma porção de tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha", bem como o importe de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), em notas de pequeno valor, e exalando forte odor de entorpecente.

Autuado em flagrante delito e conduzido ao Distrito Policial, em interrogatório formal perante a digna Autoridade Policial, GUILHERME ficou-se silente, cf. termo de interrogatório de fls. 06.

Em 09 de fevereiro de 2022, foi determinada a notificação do réu (fls. 98/99) e, com fulcro no artigo 26 do Provimento CSM n.º 2564/2020 e na necessidade de prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento reservada na modalidade virtual. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. Em seguida, a denúncia foi recebida, sendo iniciada a instrução criminal.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a ABSOLVIÇÃO do réu por insuficiência de provas. No mesmo sentido foi a manifestação da defesa.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer o mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do acusado GUILHERME pela prática do delito de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente, e do delito de corrupção de menores, ambos em período de calamidade pública e em concurso formal.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da IMPROCEDÊNCIA da ação penal, nos seguintes termos:

I) QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

É inevitável a conclusão de que a materialidade ficou suficientemente comprovada nos autos. No entanto, o mesmo não pode ser dito em relação a autoria.

A materialidade do delito resultou provada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), fotografias (fls. 15/16), laudo de constatação (fls. 18/21) e laudo pericial químico-toxicológico (fls. 115/117), que constatou que os materiais apreendidos continham drogas, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada. No entanto, o mesmo não pode ser dito em relação à autoria.

Durante o interrogatório policial, o réu GUILHERME permaneceu silente (fls. 06).

Em Juízo, o réu GUILHERME negou a prática dos crimes que lhe foram imputados.

Alegou no dia dos fatos, voltou do trabalho e foi ao ponto de drogas para comprar uma porção de maconha. Desceu até o escadão para comprar. Encontrou um rapaz sentado e, assim que se sentou ao lado dele, a polícia chegou e foram abordados. Na sua posse tinha apenas 49 reais, fruto de seu trabalho. Não sabe ao certo, mas acredita que na posse do tal rapaz a polícia também encontrou dinheiro. Não viu se o adolescente estava com drogas. Falou para os policiais que estava no local apenas para comprar drogas, mas mesmo assim foi preso. Não viu onde a polícia achou a mochila. Comprava drogas naquele ponto, pois fica na rua de cima da sua casa.

A versão apresentada pelo réu, de fato, não pode ser afastada pela prova produzida sob o crivo do contraditório, como mencionado pelas partes.

Em juízo, os policiais envolvidos no flagrante, únicas testemunhas dos fatos, apresentaram versões contraditórias e frágeis, bem como nada souberam dizer sobre a efetiva comercialização dos entorpecentes. Outrossim, um deles afirmou que uma porção de maconha foi encontrada na posse do réu. De outro lado, o outro policial alegou que a porção estava na posse do menor. Note-se, que na fase policial, ambos afirmaram que a porção foi encontrada com o menor. De outro lado, ambos afirmaram em juízo que uma mochila com drogas foi localizada cerca de três metros de distância do ponto onde estava o réu e o adolescente estavam e não ao lado de ambos, como constou na fase policial.

Assim, a testemunha HARRISON, policial militar, reconheceu o réu e narrou que no dia dos fatos deparou com os dois sentados no ponto. Eles ficaram surpresos com a presença da equipe. Durante a abordagem, o depoente ficou na segurança. Um deles estava com uma porção de drogas, dinheiro, salvo engano com os dois. Perto do local, num barranco, acharam uma bolsa preta, vários entorpecentes, maconha crack e cocaína. Eles nada disseram. A droga que estava no bolso de um deles era semelhante aquela que estava na mochila. Salvo engano, acharam dinheiro somente com eles. Trezentos ou quatrocentos com um e o outro com cinquenta. Não lembra quem estava com eles. O ponto é conhecido como de venda e consumo de drogas. Os dois não aparentavam estar usando drogas. Não era possível ver a bolsa no local onde eles estavam. Havia um barranco. O local é movimentado, tem uma quadra, aparelhos de ginástica e não houve a fuga de suspeitos quando fizeram a abordagem. Não conhecia o réu até a data dos fatos.

Da mesma forma, a testemunha HENRIQUE, policial militar, declarou que em patrulhamento viram os dois sentados no local. ao ver a equipe mostraram nervosismo. Foi realizada a abordagem e encontrada porções de maconha. Perto deles, uns três metros de distância, notou o mato amassado por passos e achou uma mochila com drogas. O depoente fez a revista. Encontrou com o réu uma porção embalada para uso e dinheiro. Na posse do menor nada de ilícito foi encontrado. Indagados a respeito da droga, ficou em silêncio. Na mochila encontraram mais porções da mesma droga, embalada da mesma forma. Eles ficaram em silêncio. durante o patrulhamento não presenciaram atos típicos. Eles estavam sentados e não estavam consumindo. Não os conhecia até a data dos fatos. O local é conhecido como ponto de vendas. Não lembra do valor em dinheiro apreendido.

Desta feita, os policiais únicas testemunhas dos fatos, apresentaram declarações frágeis e diversas das apontadas na fase policial. Assim, a prova indiciária colhida na fase administrativa, não foi confirmada em juízo e, de outra feita, as provas judicializadas da autoria, não permitem que se chegue a um decreto condenatório.

Noto que a proteção ao contraditório é de tanta importância que na reforma legislativa de 2008, foi incluída expressamente essa previsão no artigo 155 do Código de Processo Penal que diz: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito à garantia constitucional do devido processo legal, a legitimidade do poder-dever do Estado aplicar a sanção prevista em lei ao acusado da prática de determinada infração penal deve ser exercida por meio da ação penal, no seio da qual ser-lhe-á assegurada a ampla defesa e o contraditório. 2. Visando afastar eventuais arbitrariedades, a doutrina e a jurisprudência pátrias já repudiavam a condenação baseada exclusivamente em elementos de prova colhidos no inquérito policial. 3. Tal vedação foi abarcada pelo legislador ordinário com a alteração da redação do artigo 155 do Código de Processo Penal, por meio da Lei n. 11.690/2008,

o qual prevê a proibição da condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 4. Constatado que o Tribunal de origem utilizou-se unicamente de elementos informativos colhidos no inquérito policial para embasar o édito condenatório em desfavor do paciente, imperioso o reconhecimento da ofensa ao aludido dispositivo do Estatuto Processual Penal, já em vigor na data da prolação do acórdão objurgado, bem como à garantia constitucional ao devido processo legal. 5. Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório apenas com relação ao paciente, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, com a determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso." (STJ - HC: 123295 MT 2008/0272631-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2009).

A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela polícia judiciária na fase preliminar da persecução penal e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade de da instrução criminal contraditória.

A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos tribunais, cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo.

Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia.

Neste sentido: "EMENTA: I. Habeas corpus: falta de justa causa: inteligência. 1. A previsão legal de cabimento de habeas corpus quando não houver "justa causa" para a coação alcança tanto a instauração de processo penal, quanto, com maior razão, a condenação, sob pena de contrariar a Constituição. 2. Padece de falta de justa causa a condenação que se funde exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. II. Garantia do contraditório: inteligência. Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação." (STF, RE 287658 / MG - MINAS GERAIS Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 16/09/2003).

Sendo assim, diante da fragilidade da prova colhida em juízo, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de ser o acusado o autor do fato criminoso.

Em razão disso, já se decidiu: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

## II) QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Neste ponto a denúncia, de igual forma, não procede.

Isto porque, em razão da ausência de provas no tocante a participação do réu no tráfico de entorpecentes, descabido o reconhecimento do delito em tela, pois não há que se falar em corromper o menor, se sequer elementos há para atestar que o réu praticava no local qualquer delito.

Assim, o réu deverá também ser absolvido do crime previsto no artigo 244-B do ECA. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o réu GUILHERME ALVES PAGAMONHA (RG. 50849747/SP), qualificado nos autos, das sanções do 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do

Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do réu.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido e o perdimento do valor em favor da União, oficiando-se.

Providencie a serventia as comunicações de praxe.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de março de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA